חוברת 2 · מרתון

תורת המשפט

מרתון למבחן

טבלאות, שרשראות פסיקה, עצי החלטה ורשימות "חייבים לזכור"

15 פרקים

הוכן ונערך ע״י

אילן פרץ

תוכן העניינים

מרתון לפי פרקים

1 שיטות משפט בעולם והמשפחות המשפטיות

2 המשפט הישראלי ומקורותיו

3 חקיקה ראשית וחקיקת משנה

4 פרשנות חוקים ותכלית החקיקה

5 התקדים המחייב והלכת בית המשפט

6 הפרדת רשויות ושלטון החוק

7 מערכת בתי המשפט בישראל

8 המשפט המקובל מול הקונטיננטלי

9 חוקי היסוד וזכויות האדם

10 מבוא למשפט הפרטי

11 מבוא למשפט הציבורי

12 נטל ההוכחה ורף ההוכחה

13 אתיקה ומקצועות המשפט

14 כתיבה וטיעון משפטי

15 מבוא לפתרון בעיה משפטית

פרק 1

שיטות משפט בעולם והמשפחות המשפטיות

שיטות משפט והמשפחות המשפטיות

✦ **הגדרה — משפחה משפטית** קבוצת שיטות דומות במוצא, במקורות ובדרך החשיבה. כלי השוואתי, לא חוקי.

פרמטר	קונטיננטלי	מקובל
מקור	קודקס	פסיקה
תקדים	משפיע, אינו מחייב	מחייב
חשיבה	דדוקציה	אנלוגיה
דוגמאות	צרפת, גרמניה	אנגליה, ארה״ב

✔ **שורה תחתונה — מבחני סיווג** דויד: טכניקה + אידיאולוגיה. צווייגרט וקץ: סגנון משפטי (היסטוריה, חשיבה, מוסדות, מקורות, אידיאולוגיה).

✦ **הגדרה — דיני היושר** משלימים את נוקשות המשפט המקובל; מהם Trust, צו מניעה ואכיפה בעין.

✦ **הגדרה — שיטה מעורבת** שילוב יסודות ממשפחות שונות: לואיזיאנה, קוויבק, סקוטלנד, דרום אפריקה, ישראל.

✦ **הגדרה — השתלה משפטית** Legal transplant (ווטסון): העברת כלל או מוסד משיטה לשיטה, כמו הקודקס השווייצרי בטורקיה.

§ **סעיף — המג׳לה** קודקס עות׳מאני לדיני ממונות; בוטל בחוק לביטול המג׳לה, התשמ״ד־1984.

§ **סעיף — חוק יסודות המשפט, 1980** ביטל את ס׳ 46 לדבר המלך; ממלאים לקונות לפי עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.

§ **סעיף — חוק שיפוט בתי דין רבניים, 1953** שיפוט ייחודי בנישואין וגירושין של יהודים; ייערכו על פי דין תורה; התוקף מחוק הכנסת.

! **שים לב — מלכודת** ״אין פסיקה בקונטיננטלי״ שגוי; חסר כלל תקדים פורמלי בלבד.

פסק דין	הלכה
פונק־שלזינגר	פקיד הרישום רושם לפי תעודת נישואים מחו״ל; תפקידו סטטיסטי
בבלי	בית דין דתי בעניין אזרחי נלווה מפעיל את המשפט האזרחי הכללי

מילות מפתח: קודיפיקציה, stare decisis, Equity, שיטה מעורבת, legal transplant, ס׳ 46, דין תורה.

1.1 מבוא: מדוע משווים בין שיטות משפט

✦ **הגדרה — משפחה משפטית** קבוצה של שיטות משפט לאומיות בעלות מוצא היסטורי דומה, מקורות משפט דומים ודרך חשיבה משפטית דומה. זהו כלי השוואתי ולא מושג מחייב:

1.2 מבחני הסיווג

1.3 המשפחות המרכזיות

§ **סעיף — דיני היושר (Equity) באנגליה** לצד בתי המשפט של המשפט המקובל התפתחו בתי משפט של היושר, שהושתתו על שיקולי צדק והגינות והיו פתוחים לתיקון תוצאות נוקשות.

1.4 טבלה: משפט קונטיננטלי מול משפט מקובל

פרמטר	קונטיננטלי	מקובל

מקור מרכזי	קודקס וחקיקה שיטתית	פסיקה, לצד חקיקה
מעמד התקדים	משפיע בפועל, אך אינו מחייב פורמלית	מחייב (stare decisis)
שיטת החשיבה	דדוקציה: מהכלל הכללי למקרה	אנלוגיה: ממקרה למקרה
תפקיד השופט	מיישם את החוק ומפרשו	יוצר הלכה ומפתח אותה
הליך	דרך כלל חקרני (השופט מנהל)	דרך כלל יריבותי (הצדדים מנהלים)
דוגמאות	צרפת, גרמניה, ספרד, יפן	אנגליה, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה

! שים לב — אל תגזימו בהבחנה ההבדלים הם **של דגש ולא של מהות**. במשפט הקונטיננטלי יש פסיקה רבה ומשפיעה (בית המשפט הגבוה בצרפת, בגרמניה), ובמשפט המקובל יש חקיקה רבה (חוקים קודיפיקטיביים בארה״ב).

1.5 שיטות מעורבות והשתלות משפטיות

1.6 המקרה הישראלי: שיטה מעורבת

§ סעיף — דין דתי בישראל לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי״ג־1953, לבתי הדין הרבניים שיפוט **ייחודי** בנישואין וגירושין של יהודים בישראל, והם ייערכו **על פי דין תורה**.

1.7 פסיקה מרכזית

1.8 שלד לפתרון שאלה על שיטות משפט

1.9 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״במשפט הקונטיננטלי אין פסיקה״	יש פסיקה משפיעה; חסר רק כלל תקדים מחייב
״ישראל היא שיטה מקובלת טהורה״	יש חקיקה קונטיננטלית ודין דתי
״הדין הדתי חל בישראל מכוח עצמו״	תוקפו מכוח חוק הכנסת
״הסוציאליסטי היה משפחה עצמאית בוודאות״	יש מי שרואה בו חלק מהקונטיננטלית
״משפחות משפטיות הן סיווג מחייב״	זהו כלי השוואתי, ויש עליו ביקורת

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** שאלות על המשפחות המשפטיות כמעט תמיד בודקות הבחנה: **מקור מרכזי** (קודקס מול פסיקה) ו**מעמד התקדים**. כשמתארים את ישראל, הקפידו על המילה ״מעורבת״ והדגימו אותה בשלושה רבדים לפחות.

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** משפחה משפטית = שיטות בעלות מוצא, מקורות וחשיבה דומים; הסיווג נעזר בדויד (טכניקה ואידיאולוגיה) ובצווייגרט וקץ (סגנון). קונטיננטלי: קודקס; מקובל:

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג״ץ 143/62 פונק־שלזינגר נ׳ שר הפנים	ברוב דעות נקבע שפקיד הרישום חייב לרשום בני זוג שהציגו תעודת נישואים אזרחיים מחו״ל, כי תפקידו רישומי־סטטיסטי ואין הוא מוסמך להכריע בתוקף הנישואים. הרישום אינו קובע מעמד משפטי. ההלכה ממחישה את המתח בין הדין הדתי החל על נישואין בישראל לבין הכרה במעשים משפטיים אזרחיים שנעשו מחוץ לה. למבחן: זכרו שהקביעה היא על תפקיד הפקיד ולא על תוקף הנישואים.
בג״ץ 1000/92 בבלי נ׳ בית הדין הרבני הגדול	בג״ץ קבע שבית דין דתי הדן בעניינים אזרחיים נלווים שאינם מעמד אישי חייב להפעיל את המשפט האזרחי הכללי כפי שפירש אותו בית המשפט העליון, לרבות חוק שיווי זכויות האישה והלכת השיתוף. זו הלכת יסוד על הגבול בין הרובד הדתי לאזרחי בשיטה המעורבת ועל כפיפות בתי הדין לביקורת בג״ץ. למבחן: הדגימו בה את אופי השיטה המעורבת.
Donoghue v Stevenson (בית הלורדים, 1932)	בית הלורדים קבע שליצרן חובת זהירות כלפי הצרכן הסופי. עיקר ההלכה, בניסוחו של הלורד אטקין, היא עקרון ה״שכן״ (neighbour principle). זוהי דוגמה קלאסית ליצירת הלכה בפסיקה ולהתפתחות המשפט המקובל מקרה אחר מקרה, ובישראל נקלטו עקרונות דומים בדיני הנזיקין. למבחן: דוגמה לתפקיד השופט כיוצר הלכה במשפט המקובל.

פרק 2

המשפט הישראלי ומקורותיו

המשפט הישראלי ומקורותיו

✦ **הגדרה — מקור פורמלי מול היסטורי** פורמלי = מקור התוקף; היסטורי = מאין נלקח התוכן.

דרגה	מקור
1	חוקי יסוד
2	חקיקה ראשית (חוק ופקודה)
3	חקיקת משנה
4	הלכה פסוקה (ס׳ 20 לחוק־יסוד: השפיטה)
5	מנהג, משפט משווה, משפט עברי

§ **סעיף — פקודת סדרי השלטון והמשפט** ס׳ 11 רציפות; ס׳ 13 ביטול הספר הלבן; ס׳ 15(ג) ניתוק מפרשנות אנגלית.

§ **סעיף — סימן 46** בהעדר הסדר, פנו למשפט המקובל ולדיני היושר; בוטל ב־1980.

§ **סעיף — חוק יסודות המשפט** לקונה: חקיקה, הלכה, היקש, עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום; דוקטרינות שנקלטו נשארות.

! **שים לב — לקונה או הסדר שלילי** שתיקה מכוונת אינה לקונה.

✔ **שורה תחתונה — אמנות** אמנה חלה בדין הפנימי רק אם נקלטה בחקיקה; מנהג בינלאומי חל ישירות ככל שאינו סותר חוק.

פסק דין	הלכה
בנק המזרחי	עליונות חוקי היסוד, ביקורת חוקתית

קול העם	הכרזת העצמאות כמקור פרשני; ״ודאות קרובה״
הנדלס	מחלוקת אלון–ברק על מקומו של המשפט העברי

הוגה	תפיסה
קלזן	Grundnorm והיררכיית נורמות
הארט	כלל הכרה; כללים ראשוניים ומשניים
פולר	מוסריות פנימית של החוק
דבורקין	עקרונות ושלמות המשפט

מילות מפתח: מקור פורמלי, סימן 46, ס׳ 11, לקונה, הסדר שלילי, פוזיטיביזם, משפט הטבע.

2.1 מבוא: מאין שואב המשפט הישראלי את תוקפו

✦ **הגדרה — מקור פורמלי ומקור היסטורי** מקור פורמלי הוא מה שנותן לנורמה תוקף מחייב (חוק הכנסת, הלכת בית המשפט העליון). מקור היסטורי או חומרי הוא המקום שממנו נלקח תוכן הכלל (משפט גרמני, אנגלי, עברי).

2.2 הרקע ההיסטורי: מקורות המשפט בישראל

§ **סעיף — הרציפות: פקודת סדרי השלטון והמשפט, 1948** ס׳ 11 קבע שהמשפט שהיה קיים ב־14.5.1948 **ימשיך לעמוד בתוקפו**, ככל שאין בו סתירה לחוקי המדינה החדשים ולשינויים הנובעים מהקמתה.

§ **סעיף — חוק יסודות המשפט, התש״מ־1980** החוק ביטל את סימן 46. כשבית המשפט מוצא **לקונה** (חסר) ואינו מוצא תשובה בחקיקה, בהלכה פסוקה או בהיקש, יכריע לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל (נוסח מאוחר יותר הוסיף במפורש את ״המשפט העברי״).

! **שים לב — לקונה או הסדר שלילי** הפניה לחוק יסודות המשפט מותנית ב**לקונה**, כלומר בחסר בלתי מכוון. כשהמחוקק בחר שלא להעניק זכות או סעד, זה **הסדר שלילי**, ואין מה להשלים.

2.3 היררכיית המקורות

דרגה	המקור	הערות
1	חוקי יסוד	מעמד חוקתי; לפי בנק המזרחי, עליונות נורמטיבית
2	חקיקה ראשית: חוקי הכנסת ופקודות מנדטוריות	חוק הפרשנות משווה בין חוק לפקודה
3	חקיקת משנה: תקנות, צווים, כללים	מכוח הסמכה בחוק ובכפיפות לו
4	הלכה פסוקה	הלכת העליון מחייבת כל ערכאה נמוכה (ס׳ 20 לחוק־יסוד: השפיטה)
5	מנהג ועקרונות יסוד, משפט משווה, משפט השראה ומילוי חסר עברי	

2.4 המשפט העברי והזרים בפסיקה

2.5 נקודת מבט תיאורטית: פוזיטיביזם ומשפט הטבע

הוגה	עיקר התפיסה
קלזן	תורת משפט טהורה: היררכיית נורמות שמגיעה לנורמת יסוד (Grundnorm) הנחשבת תקפה
הארט	The Concept of Law: כללים ראשוניים ומשניים; כלל ההכרה (rule of recognition) קובע מהו חוק
פולר	המוסריות הפנימית של החוק: דרישות כמו פומביות, בהירות והעדר רטרואקטיביות
דבורקין	משפט כולל גם עקרונות, לא רק כללים; המשפט כשלמות (integrity)

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלה על ״מהו חוק״: פוזיטיביזם בודק תוקף לפי מקור (כלל ההכרה בישראל: חקיקת הכנסת ופסיקת העליון), משפט הטבע בודק גם תוכן.

2.6 שלד לפתרון שאלה על מקורות

2.7 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״פקודה מנדטורית היא חקיקת משנה״	זו חקיקה ראשית לפי חוק הפרשנות
״ביטול סימן 46 ביטל כל משפט אנגלי״	מה שנקלט לפני 1980 נשאר
״אמנה שאושררה חלה אוטומטית״	צריכה קליטה בחקיקה; מנהגי חל ישירות
״כל שתיקה בחוק היא לקונה״	שתיקה מכוונת היא הסדר שלילי

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** מקור פורמלי נותן תוקף; היסטורי מסביר מאין התוכן. שלושה רבדים: עות׳מאני, מנדטורי, ישראלי. ס׳ 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט יוצר רציפות.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע״א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד נ׳ מגדל כפר שיתופי	בית המשפט העליון, בהרכב מורחב, קבע שחוקי היסוד הם בעלי מעמד נורמטיבי עליון, ושלבית המשפט סמכות לבקר חקיקה רגילה הסותרת חוק יסוד. הדגש הוא על הסמכות המכוננת של הכנסת ועל פסקת ההגבלה. זהו פסק הדין המכונן של ״המהפכה החוקתית״ והוא אבן יסוד להבנת היררכיית המקורות. למבחן: זכרו את הכינוי ואת הרעיון של עליונות נורמטיבית.
בג״ץ 73/53 חברת ״קול העם״ בע״מ נ׳ שר הפנים	העתירה התקבלה. השופט אגרנט קבע שהכרזת העצמאות אינה חוקה, אך היא מבטאת את חזון העם ויש להתחשב בה בפירוש חוקי המדינה, לרבות חקיקה מנדטורית שנקלטה. מכאן נגזרה הגנה על חופש הביטוי, ונקבע מבחן ״הוודאות הקרובה״ לפגיעה באינטרס הציבורי. למבחן: מדגים כיצד חיקוק ישן מתפרש לאור ערכי המדינה.
ד״נ 13/80 הנדלס נ׳ בנק קופת עם בע״מ	בדיון הנוסף אושרה ברוב דעות ההכרעה לטובת הבנק. חשיבותו במחלוקת המתודולוגית: השופט אלון ראה במשפט העברי מקור השראה ראשי, גם בפירוש מונחים, והרוב (ובהם ברק, כהן ולנדוי) לא הכירו בו כמקור פרשני מחייב. למבחן: הציגו את שתי הגישות לצד התוצאה.
בג״ץ 1635/90 ז׳רז׳בסקי נ׳ ראש הממשלה	לצד הדיון בביקורת השיפוטית על הסכמים פוליטיים, חזרה מחלוקת אלון–ברק. ברק קבע שעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל הם חלק מעקרונות היסוד של השיטה, אך אינם המקור היחיד שאליו פונים. הגישה: מקור חשוב, לא בלעדי.

פרק 3

חקיקה ראשית וחקיקת משנה

חקיקה ראשית וחקיקת משנה

פרמטר	ראשית	משנה
מחוקק	הכנסת	רשות מבצעת
הסמכה	עצמאית	מפורשת בחוק
ביקורת	חוקתית	מינהלית
מעמד	גבוה	נמוך

✦ **הגדרה — תקנה** הוראה מכוח חוק בת־פעל תחיקתי; המהות קובעת, לא השם.

§ **סעיף — כללי עזר (חוק הפרשנות)** ס׳ 15: הסמכה כוללת תיקון, שינוי, התליה וביטול; ס׳ 23: בטלות עם החוק המסמיך.

§ **סעיף — ס׳ 37(א) לחוק־יסוד: הממשלה** שר הממונה על ביצוע חוק מתקין תקנות לביצועו.

✔ **שורה תחתונה — Ultra vires** חריגה מהסמכות = בטלות; החוק המסמיך הוא המסגרת.

✔ **שורה תחתונה — הסדרים ראשוניים** מדיניות עקרונית ואמות מידה בחקיקה ראשית; הרשות קובעת הסדרים משניים.

§ **סעיף — פגיעה בזכות** רק לפי חוק או מכוחו בהסמכה מפורשת, לתכלית ראויה ובמידתיות.

! **שים לב — תקנות שעת חירום** הכרזת חירום; פוקעות בתום תקופה אלא אם הוארכו; אסור לפגוע בכבוד האדם, לקבוע עניינה למפרע או למנוע פנייה לערכאות.

פסק דין	הלכה
בז׳רנו	אין עיסוק מוגבל בלי הסמכה
דיזנגוף	סבירות קיצונית פוסלת תקנה
מיטרני	הסדרים משניים לרשות
רובינשטיין	הסדר ראשוני בחקיקה ראשית
6198/23	אין מקור חוקי לפטור גורף מגיוס

מילות מפתח: ultra vires, הסדרים ראשוניים, הסמכה מפורשת, בת־פעל תחיקתי, ס׳ 37(א), רשומות.

3.1 מבוא: מי רשאי לקבוע נורמות מחייבות

3.2 חקיקה ראשית

3.3 חקיקת משנה

✦ **הגדרה — תקנה** לפי חוק הפרשנות, תקנה היא הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת־פעל תחיקתי, כלומר נורמה כללית ולא החלטה פרטנית. השם שניתן לה (תקנה, צו, כללים) אינו מכריע; המהות קובעת.

§ **סעיף — כללי עזר בחוק הפרשנות** הסמכה להתקין תקנות כוללת סמכות לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן באותה דרך (ס׳ 15). משבוטל חיקוק, בטלות עמו התקנות שהותקנו מכוחו (ס׳ 23), אלא אם נקבע אחרת.

3.4 היחס בין השתיים: כפיפות והסמכה

פרמטר	חקיקה ראשית	חקיקת משנה
מי מחוקק	הכנסת	רשות מבצעת (שר, רשות)
מקור הסמכות	עצמאי (חוקי היסוד)	הסמכה מפורשת בחוק
ביקורת שיפוטית	חוקתית בלבד (סתירה לחוק יסוד)	גם מינהלית: חריגה מסמכות, סבירות, מידתיות
מעמד	גבוה	נמוך, כפוף לחוק

3.5 פסיקה מרכזית

3.6 ההסדרים הראשוניים והגבלות נוספות

! שים לב — מלכודת: ביקורת על חוק ועל תקנה על תקנה חלות עילות המשפט המינהלי (סמכות, סבירות, מידתיות). על **חוק של הכנסת** הביקורת היא חוקתית בלבד, בגלל סתירה לחוק יסוד.

3.7 שלד לפתרון שאלה על חקיקת משנה

3.8 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
"פקודה מנדטורית היא חקיקת משנה"	היא חקיקה ראשית לפי חוק הפרשנות
"השם קובע: צו אינו תקנה"	המהות קובעת: נורמה כללית מכוח חוק
"אישור ועדה מרפא חריגה מסמכות"	אישור דיוני אינו מרפא חריגה מהותית
"תקנות עומדות אחרי ביטול החוק המסמיך"	בטלות עם החוק (ס' 23)

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלה על תקנה שנראית פוגענית, חפשו קודם **הסמכה**, אחר כך **הסדר ראשוני**, ואחר כך סבירות. מי שמדלג על שלב ההסמכה מפספס את הנקודה העיקרית.

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** ראשית: הכנסת (וחוקי היסוד), כולל פקודות מנדטוריות; משנה: רשות מבצעת מכוח הסמכה. תקנה היא נורמה כללית מכוח חוק, בלי קשר לשם.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה	העתירה התקבלה. נקבע שרשות אינה מוסמכת למנוע מאדם לעסוק במשלח ידו כשאין חוק המסמיך אותה לכך. זה אחד מפסקי הדין הראשונים שבהם הוכר חופש העיסוק כזכות יסוד ונפסלה פעולה של רשות בשל היעדר סמכות. למבחן: אבן יסוד לעקרון החוקיות ולמגבלות על פעולות הרשות וחקיקת המשנה.
ע"א 311/57 היועץ המשפטי לממשלה נ' מ. דיזנגוף ושות' (שיט) בע"מ	השופט ברנזון קבע שאם חקיקת משנה כה בלתי הגיונית ובלתי נסבלת עד שאדם בר דעת לא יעלה על דעתו ששר סביר היה מתקין אותה, יש להסיק שהמחוקק לא התכוון להעניק כוח כזה. חוסר סבירות קיצוני הוא עילה לפסילת תקנה, והוא מעוגן ברעיון של חריגה מן ההסמכה. למבחן: זכרו את הרף הגבוה.

בג"ץ 337/81 מיטרני נ' שר התחבורה בית המשפט קבע שההסדרים הראשוניים נתונים למחוקק, ואילו הרשות המבצעת מוסמכת להסדרים משניים בלבד. פסק הדין הוא אחד המקורות המרכזיים שעליהם נשענה דוקטרינת ההסדרים הראשוניים, שפותחה והורחבה בבג"ץ רובינשטיין. למבחן: ציינו אותו כחוליה בשרשרת הפסיקה.

בג"ץ 3267/97 רובינשטיין נ' שר הביטחון הרכב של 11 שופטים קבע שלפי עקרונות שלטון החוק והפרדת הרשויות, הכנסת חייבת לקבוע את ההסדרים הראשוניים: המדיניות הכללית ואמות המידה. בשל היקף הדחיות והמחלוקת הציבורית, זו הכרעה עקרונית שמחייבת חקיקה ראשית, והסמכות הכללית אינה מכסה אותה. הכרזת הבטלות הושעתה כדי לאפשר חקיקה. למבחן: זהו פסק הדין המרכזי בדוקטרינה.

בג"ץ 6198/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שר הביטחון בית המשפט, בהרכב מורחב של תשעה שופטים ופה אחד (2024), קבע שאין כיום מקור חוקי להימנע מגיוס תלמידי ישיבות, שעל המדינה לאכוף את חוק שירות הביטחון, שאין סמכות להמשיך להעביר כספי תמיכה לישיבות עבור תלמידים אלה, וששההוראה בהחלטת הממשלה שלא לאכוף את החוק התקבלה בחוסר סמכות. למבחן: יישום עקרון ההסדרים הראשוניים והחוקיות.

פרק 4

פרשנות חוקים ותכלית החקיקה

פרשנות חוקים ותכלית

✔ **שורה תחתונה — שלבי הפרשנות** 1. מתחם לשוני. 2. תכלית. 3. בחירת המשמעות המגשימה את התכלית. פותחים בלשון ולא מסיימים בה.

תכלית	משמעות
סובייקטיבית	כוונת המחוקק ההיסטורי
אובייקטיבית	מה שחוק כזה נועד להגשים בחברה דמוקרטית

★ **טיפ למבחן — משקל התכליות** חוק חדש וספציפי: משקל לסובייקטיבית. חוק ישן או חוקה: לאובייקטיבית.

§ **סעיף — ס׳ 34כא לחוק העונשין** כמה פירושים סבירים לפי התכלית: הפירוש המקל עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית. כלל הכרעה אחרון.

✔ **שורה תחתונה — חוק מס** לפי תכליתו; לא לטובת הנישום ולא לרעתו (חצור). ספק שלא ניתן להסירו: לטובת הפרט.

✦ **הגדרה — פרשנות מקיימת** מעדיפים פירוש סביר שאינו פוגע בזכות חוקתית על פני ביטול (חסון).

! **שים לב — מלכודת** תכלית ללא עיגון מינימלי בלשון אינה פרשנות אלא תיקון חקיקה.

פסק דין	הלכה
מזרחי	משמורת רעיונית; פרשנות לפי תכלית
חצור	חוק מס מתפרש לפי תכליתו
אלבה	פרשנות יסודות הסתה לגזענות

חסון פרשנות מקיימת לחוק יסוד

הוגה	עמדה
הארט	ליבה ואזור דמדומים
דבורקין	עקרונות ושלמות; תשובה נכונה
ברק	פרשנות תכליתית

מילות מפתח: מתחם לשוני, תכלית אובייקטיבית, פרשנות מקיימת, 34כא, אזור דמדומים.

4.1 מבוא: מדוע חוק צריך פרשנות

4.2 שלבי הפרשנות התכליתית

4.3 תכלית סובייקטיבית, אובייקטיבית וכללי משקל

סוג תכלית	מהי	מקורות
סובייקטיבית	מה שהמחוקק ההיסטורי ביקש להשיג	דברי הסבר, פרוטוקולים, היסטוריה חקיקתית
אובייקטיבית	מה שחוק כזה נועד להגשים בחברה דמוקרטית	ערכי היסוד של השיטה, זכויות אדם, חזקות פרשניות

4.4 כללי עזר, חזקות ופרשנות פלילית

§ **סעיף — ס׳ 34כא לחוק העונשין** ניתן דין לפירושים סבירים אחדים **לפי תכליתו**, יוכרע העניין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית. הסעיף הוא כלל הכרעה אחרון:

4.5 נקודת מבט תיאורטית: מי קובע את המשמעות

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלה על פרשנות מוסיפים בקצרה את העמדה התיאורטית רק כשהשאלה מבקשת זאת. מבלי להיכנס לפרטים שאינכם בטוחים בהם, אפשר לכתוב:

4.6 שלד לפתרון שאלה פרשנית

4.7 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״תכלית גוברת תמיד על הלשון״	נדרש עיגון מינימלי בלשון
״חוק פלילי מתפרש תמיד לטובת הנאשם״	רק אם נותרו כמה פירושים סבירים לפי התכלית
״חוק מס מתפרש לטובת הנישום״	מתפרש לפי תכליתו (חצור)
״פרשנות רשות מחייבת את בית המשפט״	אינה מחייבת

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** הפרשנות התכליתית: לשון, תכלית, בחירה. תכלית סובייקטיבית (כוונת המחוקק) ואובייקטיבית (ערכי השיטה); משקלן משתנה לפי גיל החוק. חוק מס: לפי תכליתו; חוק פלילי:

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע״פ 787/79 מזרחי נ׳ מדינת ישראל	השופט ברק קבע שיש לפרש את העבירה לפי תכליתה ולא לפי לשונה היבשה, ולכן גם מי שנמצא ב״משמורת רעיונית״, מחוץ לכלא אך נתון למרות השלטונות, עובר את העבירה. מכאן הרעיון שמילות החוק אינן מבצרים שיש לכבשם בעזרת מילונים. הפרשה היא נקודת מפנה של הפרשנות התכליתית. למבחן: שלבו אותה בדוגמה על מתחם לשוני ותכלית.
ע״א 165/82 קיבוץ חצור נ׳ פקיד שומה רחובות	השופט ברק קבע שחוק מס מתפרש כמו כל חוק, לפי תכליתו, ואין לפרשו לטובת הנישום ואין לפרשו לרעתו. הלשון היא נקודת המוצא: לעולם יש לפתוח בלשון החוק, אך לעולם אין לסיים בה. רק אם נותר ספק שלא ניתן להסירו, נוטים להגנה על חירות הפרט וקניינו. למבחן: שוללת את הכלל הישן של פרשנות לטובת הנישום.
ע״פ 2831/95 אלבה נ׳ מדינת ישראל	ההרכב המורחב (שבעה שופטים) דחה ברוב דעות את הערעור על ההרשעה, אך השופטים נחלקו בפרשנות יסודות העבירה: האם די במטרה להסית לגזענות, או שנדרש גם שתוכן הפרסום יהיה גזעני, והאם חל מבחן הסתברות. הפרשה ממחישה איך הכרעה פרשנית קובעת את גבולות חופש הביטוי. למבחן: דוגמה לפרשנות עבירה בתחום רגיש.
בג״ץ 5555/18 חסון נ׳ הכנסת	העתירות נדחו ברוב של 10 שופטים. הנשיאה חיות קבעה שיש להעדיף פרשנות מקיימת, ככל שהיא אפשרית וסבירה, שלפיה החוק אינו פוגע בזכויות חוקתיות, על פני פרשנות שתוביל לביטולו. השופט קרא, בדעת מיעוט, סבר שאי אפשר לבסס פרשנות מקיימת על הנחות שאינן כתובות בחוק. למבחן: דוגמה לפרשנות מקיימת של חוק יסוד.

פרק 5

התקדים המחייב והלכת בית המשפט

התקדים המחייב והלכת בית המשפט

§ **סעיף — ס׳ 20 לחוק־יסוד: השפיטה** (א) הלכה של בית משפט מנחה ערכאה נמוכה; (ב) הלכת העליון מחייבת כל בית משפט זולת העליון.

מושג	מעמד
רציו	מחייב
אמרת אגב	משכנעת בלבד
דעת מיעוט	אינה מחייבת; עשויה להפוך לרוב

✔ **שורה תחתונה — אנכי ואופקי** תקדים אנכי מחייב; אין תקדים אופקי מחייב.

✦ **הגדרה — הבחנה** שוני בעובדות מהותיות; אבחנה מלאכותית היא סטייה.

§ **סעיף — דיון נוסף (ס׳ 30)** סתירה להלכה קודמת, או חשיבות, קשיות או חידוש; לא טעות ביישום.

! **שים לב — משפט חוזר** תיק פלילי מסוים, ולא הלכה.

✔ **שורה תחתונה — כוח המשיכה** דבורקין: תקדימים מושכים גם כשאינם מחייבים.

פסק דין	הלכה
אפרופים	פרשנות חוזה חד־שלבית
סהר	תיקון 2011 אימץ את גישת אפרופים
יששכרוב	פסילה פסיקתית של ראיות
בן חיים	הסכמה לחיפוש מדעת
המר	ביטול עילת חיים בעוולה, כללי מעבר

מילות מפתח: stare decisis, רציו, אמרת אגב, הבחנה, דיון נוסף, כללי מעבר, תקדים אנכי.

5.1 מבוא: מעמד התקדים בשיטה מעורבת

5.2 הכלל: תקדים אנכי

§ **סעיף — ס׳ 20 לחוק־יסוד: השפיטה** (א) הלכה שנפסקה בבית משפט **תנחה** בית משפט של דרגה נמוכה ממנו. (ב) הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון **מחייבת** כל בית משפט זולת בית המשפט העליון.

! **שים לב — אל תבלבלו** הלכה של מחוזי **מנחה** את השלום ואינה מחייבת. פסיקה של מחוזי אחר אינה מחייבת מחוזי, אלא רק משכנעת. הלכת העליון היא המחייבת.

5.3 מה מחייב: רציו, אמרת אגב ודעת מיעוט

מושג	משמעות	מעמד
רציו (ratio decidendi)	הנימוק המשפטי החיוני להכרעה	מחייב
אמרת אגב (obiter dictum)	הערה שלא נדרשה להכרעה	אינה מחייבת; משכנעת
דעת מיעוט	עמדת שופט שנותר במיעוט	אינה מחייבת; עשויה להפוך לרוב בעתיד

5.4 הבחנה, סטייה והלכה חדשה

5.5 דיון נוסף

! **שים לב — דיון נוסף ומשפט חוזר** דיון נוסף נוגע ל**הלכה** (אזרחי ופלילי); משפט חוזר נוגע לתיק פלילי מסוים ולעיוות דין.

5.6 תגובת חקיקה

5.7 נקודת מבט תיאורטית: למה לציית לתקדים

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלה על מחויבות לתקדים, בדקו: מי נתן את ההלכה? מה הדרגה? האם זה רציו או אמרת אגב? האם אפשר להבחין?

5.8 שלד לפתרון שאלה

5.9 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״כל הלכה של מחוזי מחייבת שלום״	היא מנחה בלבד
״העליון כבול להלכותיו״	אינו כבול, אך נוהג בריסון
״כל מה שנכתב בפסק דין מחייב״	רק הרציו
״דיון נוסף על כל טעות ביישום״	נדרשת הלכה חדשה, קשה או סותרת
״הכנסת ביטלה את הפרשנות של בית המשפט״	פרשנות החוק החדש נשארת בידי בית המשפט

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** ס׳ 20: תקדים אנכי; העליון אינו כבול; מחוזי מנחה שלום. רציו מחייב; אמרת אגב ודעת מיעוט משכנעות. הבחנה בעובדות מהותיות; סטייה בעליון לאור הסתמכות ויציבות.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע״א 4628/93 מדינת ישראל נ׳ אפרופים שיכון וייזום (1991) בע״מ	הנשיא ברק קבע שחוזה מתפרש בתהליך חד־שלבי, שבו נבחנים יחד לשון החוזה והנסיבות החיצוניות כדי לברר את אומד דעת הצדדים. ההלכה חייבה את כל הערכאות ואושרה בדיון נוסף, ועוררה תגובת חקיקה ב־2011. זו דוגמה מרכזית לכוחה של הלכה פסוקה. למבחן: ציינו את ההשפעה על כל הערכאות ואת תגובת המחוקק.
רע״א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ׳ סהר חברה לתביעות בע״מ	דעת הרוב קבעה שהתיקון הוא למעשה אימוץ של הגישה הפרשנית של אפרופים, תוך הדגשת מקומה החשוב של לשון החוזה. השופט הנדל סבר בדעת מיעוט שהתיקון נועד לשנות את המצב. הפרשה מראה שגם כשהמחוקק מגיב להלכה, הפרשנות של החוק החדש נשארת בידי בית המשפט. למבחן: יחס בין חקיקה לפסיקה.

ע"פ 5121/98 ישששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי — העליון (השופטת ביניש) אימץ לראשונה דוקטרינת פסילה פסיקתית לראיות שהושגו שלא כדין, בהשראת חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, ופסל את ההודאה. הדוקטרינה אינה כתובה בחוק, מקורה בהלכה, והיא מחייבת מאז את כל הערכאות. זו דוגמה להלכה פסוקה כמקור משפט יוצר. למבחן: הלכה כמקור משפט.

רע"פ 10141/09 בן חיים נ' מדינת ישראל — נקבע שהסכמה מכשירה חיפוש כזה רק אם היא הסכמה מדעת, והסכמה כזו מתגבשת רק אחרי שהשוטר הבהיר שמותר לסרב ושלא יאונה רע למסרב. הלכת בן חיים חייבה מאז את הערכאות הנמוכות ואת רשויות האכיפה. למבחן: דוגמה להלכה עם השפעה מעשית על רשויות.

ע"א 1326/07 המר נ' עמית — העליון ביטל הלכה שלו: את עילת "חיים בעוולה" של הילד, והרחיב את עילת ההורים, תוך קביעת כללי מעבר להגנה על הסתמכות. פסק הדין מדגים שהעליון אינו כבול להלכותיו ויכול לסטות מהן בנימוק, תוך התחשבות ביציבות ובהסתמכות. למבחן: דוגמה לתקדים אופקי שאינו מחייב.

פרק 6

הפרדת רשויות ושלטון החוק

הפרדת רשויות ושלטון החוק

✦ **הגדרה — הפרדת רשויות** מחוקקת, מבצעת, שופטת, עם איזונים ובלמים; בישראל משטר פרלמנטרי והפרדה חלשה.

מובן	תוכן
שלטון חוק פורמלי	כולם כפופים לחוק; הסמכה; כלליות ופומביות
שלטון חוק מהותי	תוכן ראוי: זכויות, שוויון, צדק

§ **סעיף — ס׳ 3 לחוק־יסוד: הממשלה** הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת.

§ **סעיף — ס׳ 28 לחוק־יסוד: הממשלה** אי־אמון קונסטרוקטיבי: רוב חברי הכנסת מביע אמון בממשלה חלופית.

§ **סעיף — ס׳ 2 לחוק־יסוד: השפיטה** אין מרות על שופט זולת מרותו של הדין.

✔ **שורה תחתונה — חוקיות המינהל** רשות פועלת רק מכוח הסמכה בדין.

פסק דין	הלכה
דויקאת	ציות הממשלה לפסק דין; פינוי יישוב
דפי זהב	סבירות כעילה עצמאית; מתחם הסבירות
רסלר	עותר ציבורי; שפיטות נורמטיבית ומוסדית
דרעי ופנחסי	הימנעות מהעברת שר מתפקידו עלולה להיות בלתי סבירה
5658/23	ביקורת על חוקי יסוד במקרים חריגים; תיקון 3 בוטל

הוגה	תפיסה
דייסי	עליונות החוק ושוויון

פולר	דרישות פנימיות מהחוק
ראז	תפיסה דקה
דבורקין	תפיסה עבה, זכויות

> **! שים לב — מלכודת** "הרשות רשאית כל מה שלא נאסר" שגוי; זהו כלל הפרט.

מילות מפתח: איזונים ובלמים, חוקיות המינהל, עותר ציבורי, שפיטות, אי־אמון קונסטרוקטיבי, חוקי יסוד.

6.1 מבוא: מדוע מגבילים את השלטון

6.2 הפרדת רשויות

פרמטר	משטר פרלמנטרי (ישראל)	משטר נשיאותי (ארה"ב)
הממשלה	צומחת מהכנסת ותלויה באמונה	הנשיא נבחר ישירות
הפרדה בין מחוקקת למבצעת	חלשה: שרים הם לרוב חברי כנסת	חזקה יותר
כלי בקרה	אי־אמון, פיזור, ביקורת שיפוטית	וטו, הדחה, ביקורת שיפוטית
דוגמה	ס׳ 3 לחוק־יסוד: הממשלה: הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת	בחירה נפרדת ותקופת כהונה קבועה

> **§ סעיף — אי־אמון קונסטרוקטיבי** ס׳ 28 לחוק־יסוד: הממשלה קובע שהכנסת מביעה אי־אמון ברוב חבריה, כשהיא מביעה אמון בממשלה חלופית שהודיעה על קווי היסוד, הרכבה וחלוקת התפקידים.

> **§ סעיף — עצמאות השפיטה** ס׳ 2 לחוק־יסוד: השפיטה: בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת **מרותו של הדין**. זהו תנאי הכרחי לשלטון החוק, שכן שופט תלוי אינו יכול לבקר את הרשויות האחרות.

6.3 שלטון החוק: פורמלי ומהותי

מובן	תוכן
פורמלי	כולם, כולל השלטון, כפופים לחוק; פעולות הרשות טעונות הסמכה בדין; החוק פומבי, כללי וצופה פני עתיד
מהותי	לחוק עצמו תוכן ראוי: זכויות אדם, שוויון, צדק

6.4 נקודת מבט תיאורטית: מה יש לדרוש משלטון החוק

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** כשנשאלים על שלטון החוק, פתחו בהגדרה, הבחינו בין פורמלי למהותי, והדגימו (חוקיות המינהל, ציות לפסקי דין, עצמאות שפיטה). אם יש ספק לגבי ייחוס עמדה להוגה מסוים, נסחו באופן כללי:

6.5 הביקורת השיפוטית והוויכוח הציבורי

! **שים לב — הצגה מאוזנת** במבחן על נושא שנוי במחלוקת יש להציג את טיעוני שני הצדדים ואת ההכרעה המחייבת, ולא לנקוט עמדה פוליטית.

6.6 שלד לפתרון שאלה

6.7 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״הפרדת רשויות פירושה ניתוק מוחלט״	הכוונה לחלוקה עם איזונים ובלמים
״ברשות מותר מה שלא נאסר״	זה הכלל לפרט; לרשות נדרשת הסמכה
״שלטון החוק פורמלי בלבד״	יש גם מובן מהותי
״בג״ץ מתערב בכל שאלה פוליטית״	יש מבחני שפיטות ועמידה

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** הפרדת רשויות = חלוקת סמכויות + איזונים ובלמים; בישראל משטר פרלמנטרי והפרדה חלשה יחסית. שלטון החוק: פורמלי (כפיפות) ומהותי (תוכן); חוקיות המינהל.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה

בג״ץ 390/79 דויקאת נ׳ ממשלת ישראל	בית המשפט (המשנה לנשיא לנדוי) קבע שאין מניעה עקרונית להקמת יישוב מטעמים צבאיים, אך במקרה זה לא הוכח שהצורך הצבאי היה המטרה העיקרית, ולכן הורה על פינוי המקום. הממשלה, אף שתמכה בהתיישבות, קיימה את פסק הדין. הפרשה נחשבת סמל לציות השלטון לפסקי דין ולשלטון החוק. למבחן: דוגמה לציות לפסק דין שאינו נוח לשלטון.
בג״ץ 389/80 דפי זהב בע״מ נ׳ רשות השידור	העתירה נדחתה. השופט ברק קבע שחוסר סבירות הוא עילה עצמאית לפסילת החלטה מינהלית, אך הכיר במתחם הסבירות של הרשות. הנשיא לנדוי סבר שחוסר סבירות כשלעצמו, בלי שרירות, אינו מספיק. פסק הדין ביסס את הגישה המרחיבה לעילת הסבירות, שעמדה במרכז הדיון הציבורי ב־2023. למבחן: זכרו את שתי הגישות.
בג״ץ 910/86 רסלר נ׳ שר הביטחון	העתירה נדחתה לגופה, אך נקבעו הלכות יסוד: ברק הכיר בעותר הציבורי בבעיה ציבורית הנוגעת לשלטון החוק, והבחין בין שפיטות נורמטיבית לשפיטות מוסדית, וקבע שהעתירה שפיטה בשני המובנים. בן־פורת ראתה בשפיטות בעיקר עניין של ריסון עצמי. למבחן: שתי הלכות: עותר ציבורי ושפיטות.
בג״ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ׳ הכנסת	ב־1.1.2024 נקבע, ברוב של 12 מתוך 15, שלבג״ץ סמכות לבקר חוקי יסוד ולהתערב במקרים חריגים וקיצוניים של חריגה מהסמכות המכוננת; וברוב של 8 מול 7 שהתיקון בטל, בשל פגיעה חסרת תקדים בהפרדת הרשויות ובשלטון החוק. במיעוט נחלקו: פרשנות מקיימת (וילנר, שטיין וכנפי־שטייניץ), שלילת הסמכות (סולברג ומינץ), רף שלא הושג (כשר) ואי־בשלות (אלרון). למבחן: הציגו בנייטרליות את שתי העמדות.

פרק 7

מערכת בתי המשפט בישראל

מערכת בתי המשפט

ערכאה	תפקיד
שלום	ערכאה ראשונה לרוב התיקים
מחוזי	סמכות שיורית; ערעור על שלום
עליון	ערעור ברשות, בג״ץ, דיון נוסף

§ **סעיף — חוק־יסוד: השפיטה** עצמאות שפיטה (ס׳ 2), בג״ץ (ס׳ 15), זכות ערעור.

§ **סעיף — חוק בתי המשפט וחוק־יסוד: השפיטה** סמכויות עניינית ומקומית; הלכה מחייבת (חוק־יסוד: השפיטה, ס׳ 20); דיון נוסף (חוק בתי המשפט, ס׳ 30); סמכות נגררת (חוק בתי המשפט, ס׳ 76).

✔ **שורה תחתונה — סמכות** עניינית: לפי חוק ולא בהסכמה. מקומית: ניתנת לשינוי בתניית שיפוט. סכום נבחן ביום הגשה.

✦ **הגדרה — בג״ץ** סמכות שיורית ובשיקול דעת, סעד למען הצדק; אין ערעור.

✦ **הגדרה — דיון נוסף** בחינת הלכה מחדש: סתירה להלכה קודמת או חשיבות, קשיות וחידוש.

בית דין	עיקר
עבודה	נציגי ציבור; ביקורת בג״ץ מצומצמת על הארצי
דתיים	סמכות ייחודית בנישואין וגירושין של יהודים
מינהליים	עתירות נגד רשויות; ערעור לעליון

פסק דין	הלכה
אמיר	התערבות בג״ץ בבית דין דתי רק במקרים חריגים
פלונית 2232/03	בית הדין הרבני מתיר נישואין אזרחיים שנערכו בחו״ל

לב צו עיכוב יציאה: סבירות ואיזון עם חופש התנועה

! שים לב — מלכודת דיון נוסף אינו מיועד לטעות ביישום הלכה ידועה.

מילות מפתח: סמכות עניינית, תניית שיפוט, גלגול שלישי, בג"ץ, דיון נוסף, נציגי ציבור.

7.1 מבוא: מבנה הערכאות ומקורותיו

7.2 הערכאות הרגילות

ערכאה	תפקיד
בית משפט השלום	ערכאה ראשונה לרוב התיקים: אזרחיים עד סכום שנקבע בחוק, תביעות חזקה ושימוש במקרקעין בכל שווי, ועבירות פליליות שעונשן עד שבע שנות מאסר
בית המשפט המחוזי	ערכאה ראשונה בעניינים כבדים (סמכות שיורית) וערכאת ערעור על פסקי דין של השלום
בית המשפט העליון	ערכאת ערעור על המחוזי (ברשות ב"גלגול שלישי"), בג"ץ ודיון נוסף

§ סעיף — סמכות עניינית וסמכות מקומית **סמכות עניינית** נקבעת בחוק ואינה ניתנת להסכמה: הצדדים אינם יכולים להקנות סמכות למחוזי בעניין השייך לשלום. **סמכות מקומית** (איפה) ניתנת לשינוי בתניית שיפוט.

§ סעיף — סמכות נגררת כשמתעוררת בדרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה, בית המשפט רשאי להכריע בה לצורך העניין שלפניו, גם אם בדרך כלל היא בסמכות ערכאה אחרת (ס' 76 לחוק בתי המשפט).

7.3 בית המשפט העליון: ערעור, בג"ץ ודיון נוסף

! שים לב — דיון נוסף ומשפט חוזר דיון נוסף נוגע ל**הלכה** שנפסקה בעליון (אזרחי ופלילי); משפט חוזר נוגע לתיק פלילי מסוים ולתיקון עיוות דין.

7.4 בתי דין מיוחדים וערכאות נוספות

גוף	תחום
בתי הדין לעבודה (אזוריים וארצי)	יחסי עבודה וביטוח לאומי; בהרכב שבו יושבים גם נציגי ציבור של עובדים ומעסיקים; על הארצי אין ערעור וחל ביקורת בג״ץ מצומצמת
בתי המשפט לענייני משפחה	סכסוכים משפחתיים אזרחיים
בתי הדין הדתיים	מעמד אישי; סמכות ייחודית בנישואין וגירושין של יהודים לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (1953)
בתי הדין הצבאיים	עבירות של חיילים
בתי המשפט לעניינים מינהליים	עתירות נגד רשויות בתחומים שנקבעו בחוק; ערעור לעליון

7.5 עקרונות היסוד והמינוי

7.6 נקודת מבט תיאורטית קצרה: מי שופט את מי

7.7 שלד לפתרון שאלה על סמכות

7.8 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״הצדדים יכולים להסכים על כל בית משפט״	סמכות עניינית נקבעת בחוק
״על בג״ץ אפשר לערער״	אין ערעור; אפשר דיון נוסף
״דיון נוסף כשהשופטים טעו״	נדרשת הלכה העומדת בעילה
״בג״ץ ערכאת ערעור על בתי הדין הדתיים״	מתערב במקרים חריגים בלבד

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** שלום, מחוזי, עליון (ערעור, בג״ץ, דיון נוסף); חוק־יסוד: השפיטה וחוק בתי המשפט. סמכות עניינית לפי חוק; מקומית ניתנת לשינוי בתניית שיפוט.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה

בג"ץ 8638/03 אמיר נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים	העתירה התקבלה. נקבע שהתערבות בג"ץ בהחלטות בתי דין דתיים מוגבלת למקרים קיצוניים: חריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי, סטייה מהוראות חוק המופנות לבית הדין או צורך בסעד מן הצדק. ההכרעה סימנה שבית הדין הרבני אינו מוסמך לשמש כבורר בסכסוך אזרחי, וסמכותו נובעת מהחוק ולא מהסכמת הצדדים. למבחן: זכרו את רשימת עילות ההתערבות.
בג"ץ 2232/03 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי תל אביב־יפו	נקבע שלבתי הדין הרבניים סמכות ייחודית להתיר גם נישואין אזרחיים של יהודים שנערכו בחו"ל, ושהעילה המתאימה להתרתם היא עצם התמוטטות הנישואין, ולא בהכרח עילת גירושין דתית. פסק הדין ממחיש את היקף הסמכות הייחודית בענייני גירושין. למבחן: הדגימו בו את הקשר בין סמכות ייחודית לבין שיטה מעורבת.
בג"ץ 3914/92 לב נ' בית הדין הרבני האזורי בתל אביב־יפו	נקבע שלבתי הדין הדתיים, ככל ערכאה שיפוטית, יש סמכות טבועה לקבוע את סדרי הדין שלהם, אך זו סמכות שלטונית שיש להפעילה בסבירות ותוך איזון ראוי עם זכויות היסוד, כמו חופש התנועה. בית דין דתי אינו פועל בחלל חוקתי. למבחן: דוגמה לחלות זכויות יסוד על גוף דתי.
בג"ץ 1074/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה	בג"ץ קיבל את העתירה והתערב בפסק הדין של בית הדין הארצי: הוא סיווג שביתות לכלכליות, פוליטיות ו"מעין־פוליטיות", וקבע ששביתה מעין־פוליטית מצדיקה לכל היותר שביתת מחאה קצרה. פסק הדין מראה שהפיקוח של בג"ץ על בתי הדין לעבודה, אף שהוא מצומצם, אינו תיאורטי. למבחן: דוגמה להתערבות בג"ץ בבית דין מיוחד.

פרק 8

המשפט המקובל מול הקונטיננטלי

המשפט המקובל מול הקונטיננטלי

פרמטר	קונטיננטלי	מקובל
מקור	קודקס	תקדים
חשיבה	דדוקציה	אנלוגיה
הליך	חקירתי	יריבותי
סגנון	קצר וקולקטיבי	ארוך ואישי

✦ **הגדרה — stare decisis** הערכאות כפופות להלכות קודמות; הרציו מחייב, אמרת אגב משכנעת בלבד.

✔ **שורה תחתונה — ישראל** תקדים מחייב והליך יריבותי (אנגלו־אמריקאי) לצד חקיקה קודיפיקטיבית ותום לב (קונטיננטלי); אין מושבעים.

§ **סעיף — תום לב** ס׳ 12, 39 לחוק החוזים; ס׳ 61(ב) מרחיב לפעולות וחיובים שאינם חוזיים.

§ **סעיף — ס׳ 167 לחסד״פ** רכיב חקירתי: הזמנת עד ביוזמת בית המשפט אחרי סיום הצדדים.

§ **סעיף — פקודת הנזיקין** ס׳ 1: פרשנות לפי עיקרי הפרשנות באנגליה; שריד מנדטורי.

! **שים לב — קוד נפוליאון** ס׳ 4: אסור לסרב לפסוק; ס׳ 5: אסור לפסוק בהוראות כלליות.

פסק דין	הלכה
קל בנין	תום לב במשא ומתן; פיצויי קיום
אפרופים	פרשנות חוזה: לשון ונסיבות יחד
יששכרוב	פסילה יחסית פסיקתית של ראיות

הוגה	רעיון
הולמס	חיי המשפט הם ניסיון
הארט	שיקול דעת באזור הדמדומים
דבורקין	רומן בשרשרת

מילות מפתח: אדברסרי, אינקוויזיטורי, קודיפיקציה, stare decisis, תום לב, רומן בשרשרת.

8.1 מבוא: העמקת ההשוואה

8.2 מקור הנורמה ושיטת החשיבה

פרמטר	קונטיננטלי	מקובל
מקור ראשי	קודקס	תקדים וחקיקה
חשיבה	דדוקציה	אנלוגיה
הליך	חקירתי (אינקוויזיטורי)	יריבותי (אדברסרי)
סגנון פסק דין	קצר, קולקטיבי, בלי דעות מיעוט	ארוך, אישי, עם דעות מיעוט
תפקיד השופט	חוקר ומיישם	פוסק ויוצר הלכה
דוגמה	צרפת, גרמניה	אנגליה, ארה״ב

✦ **הגדרה — הליך יריבותי מול חקירתי** בהליך **יריבותי** הצדדים מביאים ראיות, חוקרים נגדית, והשופט מכריע כצופה. בהליך **חקירתי** השופט אוסף ראיות ושואל עדים. החקירה הנגדית היא כלי הליבה של הדגם היריבותי לבחינת מהימנות.

8.3 המשפט הישראלי כשיטה מעורבת

§ **סעיף — תום הלב כעיקרון כללי** ס׳ 12 ו־39 לחוק החוזים מחייבים תום לב במשא ומתן ובקיום חוזה ובשימוש בזכות חוזית. ס׳ 61(ב) מחיל את הוראות החוק בשינויים המחויבים על פעולות משפטיות וחיובים שאינם חוזיים.

8.4 נקודת מבט תיאורטית: מי יוצר את המשפט

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** שאלות השוואה נבחנות לרוב בטבלה של ארבעה עד שישה פרמטרים. אל תשכחו לסיים בישראל, ולהדגים כל רכיב (תקדים, תום לב, הליך יריבותי, חוק החוזים).

8.5 שלד לפתרון שאלה

8.6 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״במשפט הקונטיננטלי אין פסיקה״	יש פסיקה; אין תקדים מחייב פורמלי
״בישראל יש מושבעים״	אין בישראל חבר מושבעים
״ישראל פונה למשפט האנגלי בלקונה״	סימן 46 בוטל ב־1980
״ההליך בישראל חקירתי״	אדברסרי, עם רכיבים חקירתיים מוגבלים

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** קונטיננטלי: קודקס, דדוקציה, הליך חקירתי; מקובל: תקדים, אנלוגיה, הליך יריבותי. ישראל: תקדים מחייב והליך יריבותי לצד חקיקה קודיפיקטיבית ועקרונות כמו תום לב.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע״א 6370/00 קל בנין בע״מ נ׳ ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע״מ	הנשיא ברק תיאר את ס׳ 12 ו־39 לחוק החוזים, והרחבתם בס׳ 61(ב), כהוראות יסוד של שיטת המשפט, המחייבות לנהוג בהגינות. נקבע שבנסיבות מתאימות ניתן לפסוק פיצויי קיום בשל הפרת חובת תום הלב במשא ומתן. למבחן: דוגמה לעיקרון כללי בסגנון קונטיננטלי המפותח בפסיקה.
ע״א 4628/93 מדינת ישראל נ׳ אפרופים שיכון וייזום (1991) בע״מ	ברוב דעות התקבל הערעור. השופט ברק דחה את גישת ״שני השלבים״ (קודם לשון, ורק אם אינה ברורה, נסיבות) וקבע שהפרשנות מכוונת לתכלית ובוחנת את הלשון ואת הנסיבות יחד. פסק הדין ממחיש שופט ישראלי שמפתח כלל רחב מתוך הוראות קצרות של קודיפיקציה. למבחן: שילוב בין המסורות.
ע״פ 5121/98 יששכרוב נ׳ התובע הצבאי הראשי	ברוב דעות אימץ בית המשפט דוקטרינה פסיקתית של פסילה יחסית: ראיה שהושגה שלא כדין תיפסל אם קבלתה תפגע באופן מהותי בזכות להליך הוגן, לפי שיקול דעת ובהתחשב בנסיבות. השופט גרוניס, בדעת מיעוט, פקפק בכך שדוקטרינה רחבה כזו צריכה להיקבע בפסיקה ולא בחקיקה. למבחן: דוגמה להלכה שנוצרה בהיעדר חוק.

דנ"א 2401/95 נחמני נ' נחמני בדיון הנוסף, בהרכב מורחב, הוכרעה המחלוקת ברוב דעות, והתוצאה של הערעור המקורי התהפכה: נקבע שאין להשתיל את הביציות המופרות בלי הסכמת הבעל. פסק הדין כלל דיון מעמיק בערכים, בדיני חוזים ובמשפט משווה, והציג דעות מיעוט ארוכות. למבחן: דוגמה לשופט הישראלי המכריע בשאלות חדשות בהיעדר חוק, בסגנון המשפט המקובל, ולהיפוך תוצאה בדיון נוסף.

פרק 9

חוקי היסוד וזכויות האדם

חוקי היסוד וזכויות האדם

✦ **הגדרה — החלטת הררי** 1950: החוקה תיבנה פרק אחר פרק בחוקי יסוד.

חוק יסוד	תוכן
כבוד האדם וחירותו	חיים, גוף, כבוד, קניין, פרטיות, פסקת הגבלה, שמירת דינים
חופש העיסוק	עיסוק; פסקת התגברות

§ **סעיף — פסקת ההגבלה (ס׳ 8)** בחוק או מכוחו; הולם ערכי המדינה; תכלית ראויה; במידה שאינה עולה על הנדרש.

✔ **שורה תחתונה — מידתיות** 1. קשר רציונלי. 2. האמצעי שפגיעתו פחותה. 3. מידתיות במובן הצר.

§ **סעיף — פסקת התגברות** רק בחוק־יסוד: חופש העיסוק; רוב של חברי הכנסת; אמירה מפורשת; תוקף קצוב.

§ **סעיף — שמירת דינים (ס׳ 10)** חוק קיים נשמר, אך תיקון חדש נבחן לפי פסקת ההגבלה.

✦ **הגדרה — סמכות מכוננת** הכנסת פועלת כרשות מכוננת בחקיקת חוקי יסוד (ברק); אינה כל־יכולה (חסון).

פסק דין	הלכה
ברגמן	שריון פורמלי של ס׳ 4 לחוק־יסוד: הכנסת
בנק המזרחי	עליונות חוקי היסוד; ביקורת שיפוטית
המרכז האקדמי	בית סוהר פרטי בוטל; פגיעה לא מידתית
חסן	חזקה חלוטה בלתי חוקתית; קיום אנושי בכבוד

5658/23 ביקורת על חוקי יסוד במקרים חריגים

גישה	עמדה
פוזיטיביזם	תוקף לפי כלל ההכרה
משפט הטבע	חוק בלתי נסבל מאבד תוקף (ראדברוך)
basic structure	גרעין חוקתי שלא ניתן לתקן (Kesavananda)

מילות מפתח: סמכות מכוננת, מידתיות, פסקת הגבלה, התגברות, שמירת דינים, שימוש לרעה בסמכות מכוננת.

9.1 מבוא: הקומה החוקתית של המשפט הישראלי

9.2 החלטת הררי וחוקי היסוד

חוק יסוד	תוכן עיקרי
כבוד האדם וחירותו (1992)	זכויות לחיים, גוף וכבוד (ס׳ 2), קניין (ס׳ 3), הגנה על החיים, הגוף והכבוד (ס׳ 4), חירות אישית, פרטיות וצנעת הפרט (ס׳ 7), פסקת הגבלה (ס׳ 8) ושמירת דינים (ס׳ 10)
חופש העיסוק (1994)	זכות אזרח או תושב לעסוק בכל עיסוק; כולל פסקת התגברות
הכנסת, הממשלה, השפיטה	הסדרי משטר ומוסדות

9.3 פסקת ההגבלה ומבחני המידתיות

§ **סעיף — פסקת ההגבלה (ס׳ 8)** אין פוגעים בזכויות שלפי חוק היסוד אלא **בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש**, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

§ **סעיף — פסקת התגברות ושמירת דינים פסקת ההתגברות** קיימת בחוק־יסוד: חופש העיסוק בלבד: חוק שנחקק ברוב חברי הכנסת ובו אמירה מפורשת שהוא תקף על אף החוק, תוקפו מוגבל לתקופה קצובה.

9.4 ביקורת שיפוטית וסמכות מכוננת

9.5 נקודת מבט תיאורטית: סמכות מכוננת, משפט הטבע ופוזיטיביזם

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** שאלה על ביקורת על חוקי יסוד דורשת שלושה רכיבים: ההכרעה המחייבת (5658/23), הטיעון נגד (פוזיטיביזם, שמירה על סמכות הכנסת), והטיעון בעד (גרעין דמוקרטי).

9.6 שלד לפתרון שאלה חוקתית

9.7 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״בחוק היסוד הוגדר במפורש חופש הביטוי״	אין; זכויות כאלה נגזרות מכבוד האדם
״פסקת התגברות יש בשני חוקי הזכויות״	רק בחופש העיסוק
״חוק מ־1985 בטל אוטומטית עם חוק היסוד״	שמירת דינים מגינה עליו; תיקון חדש נבחן
״ביקורת על חוק יסוד אינה אפשרית״	בג״ץ 5658/23: אפשרית במקרים חריגים

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** חוקי יסוד נבנים פרק אחר פרק (החלטת הררי); מעמדם העליון נקבע בבנק המזרחי. פסקת ההגבלה: חוק, ערכי המדינה, תכלית ראויה, מידתיות (שלושה מבחנים).

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג״ץ 98/69 ברגמן נ׳ שר האוצר	בית המשפט העליון קבע שחוק שפוגע בשוויון בבחירות ולא התקבל ברוב הנדרש בשריון אינו תקף ואין לפעול לפיו. פסק הדין הוא ציון דרך בביקורת השיפוטית על חקיקה, ובבסיס ההכרה בשריון פורמלי של הוראות חוקי יסוד. למבחן: הקדמה לבנק המזרחי, שנסמכה על הרעיון.
ע״א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע״מ נ׳ מגדל כפר שיתופי	בהרכב של תשעה שופטים (1995) נקבע שלחוקי היסוד מעמד חוקתי על־חוקי ושבית המשפט מוסמך להכריז על בטלות חוק הפוגע בזכות מוגנת שלא בהתאם לפסקת ההגבלה. הקניין פורש בהרחבה וכלל חוב חוזי. במקרה עצמו החוק עמד בפסקת ההגבלה ולא בוטל. למבחן: זהו פסק הדין המכונן; ציינו את תורת הסמכות המכוננת.
בג״ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ׳ שר האוצר	בית המשפט הכריז על בטלות התיקון (2009): העברת סמכויות הכליאה לגוף פרטי הפועל למטרות רווח פוגעת בחירות האישית ובכבוד האדם של האסירים מעבר לפגיעה הטבועה במאסר, ופגיעה זו אינה מידתית. למבחן: דוגמה לביקורת חוקתית ויישום מבחני המידתיות.

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי

העתירה התקבלה וההוראה הוכרזה בלתי חוקתית (2012). נקבע שהחזקה החלוטה פוגעת בזכות לקיום אנושי בכבוד, הנגזרת מכבוד האדם, ואינה עומדת בדרישת המידתיות, שכן ניתן לבחון את מצבו של כל מבקש לגופו. למבחן: הזכות החברתית כגזירה מכבוד האדם.

בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת

ב־1.1.2024 קבעו 12 מתוך 15 שופטים שלבית המשפט סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים חריגים וקיצוניים של חריגה מהסמכות המכוננת, ו־8 מתוך 15 קבעו שהתיקון בטל בשל פגיעה חמורה וחסרת תקדים במאפיינים הגרעיניים של ישראל כמדינה דמוקרטית. השופטים סולברג ומינץ שללו את עצם הסמכות. למבחן: הציגו נייטרלית את הרוב ואת הדעות החולקות.

פרק 10

מבוא למשפט הפרטי

מבוא למשפט הפרטי

✦ **הגדרה — משפט פרטי** יחסים אופקיים בין שווים; אוטונומיה של הרצון.

ענף	עניין
חוזים	התחייבות רצונית
נזיקין	אחריות לנזק
עשיית עושר	השבת התעשרות שלא כדין
קניין	זכויות בנכס
משפחה וירושה	מעמד אישי וממון

✔ **שורה תחתונה — חוזית מול קניינית** חוזית: כלפי צד מסוים. קניינית: בנכס עצמו, כלפי כל העולם.

§ **סעיף — תום לב** ס׳ 12 משא ומתן; ס׳ 39 קיום ושימוש בזכות; ס׳ 61(ב) מחוץ לחוזים; מבחן אובייקטיבי.

§ **סעיף — ס׳ 30** חוזה בלתי חוקי או נוגד תקנת ציבור בטל.

✔ **שורה תחתונה — תחולה עקיפה** זכויות אדם במשפט הפרטי דרך תקנת הציבור ותום הלב (קסטנבאום).

פסק דין	הלכה
קסטנבאום	תנאי מקפח וכיתוב לועזי: תקנת הציבור
שביט	חלופה תיאורטית אינה מספיקה
גנז	תום לב עיקרון מלכותי; גם בקניין
רוקר	אדם לאדם – אדם
אדרס	רווחי מפר מכוח עשיית עושר

✦ **הגדרה — צדק מתקן וחלוקתי** מתקן: בין שני צדדים (פרטי); חלוקתי: חלוקת משאבים (ציבורי).

מילות מפתח: אוטונומיה, in rem, תום לב, תקנת הציבור, תחולה עקיפה, גוף דו־מהותי.

10.1 מבוא: החלוקה בין פרטי לציבורי

✦ **הגדרה — משפט פרטי** הדין המסדיר יחסים בין פרטים שווי מעמד (בני אדם ותאגידים) לבין עצמם. המאפיין: אוטונומיה של הרצון וחופש לעצב את היחסים, בכפוף לדין.

! שים לב — מבחן תכליתי המדינה יכולה להיות צד במשפט פרטי (כשהיא חותמת על חוזה רכש), ופרט יכול להיות כפוף לדין ציבורי (כשהוא מפעיל סמכות שלטונית).

10.2 ענפי המשפט הפרטי

ענף	עניינו
דיני חוזים	התחייבויות רצוניות בין צדדים
דיני נזיקין	אחריות לנזק שנגרם שלא בהסכמה
עשיית עושר ולא במשפט	השבת התעשרות שלא על פי זכות שבדין (ס׳ 1 לחוק)
דיני קניין	זכויות בנכסים (מקרקעין ומיטלטלין)
דיני תאגידים	חברות ושותפויות
דיני משפחה וירושה	מעמד אישי, יחסי ממון, צוואות

10.3 עקרונות על: תום לב, חופש החוזים והקניין

§ **סעיף — תום לב בחוק החוזים** ס׳ 12: במשא ומתן יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. ס׳ 39: בקיום חיוב הנובע מחוזה, **והוא הדין בשימוש בזכות הנובעת מחוזה**.

10.4 זכויות האדם במשפט הפרטי: תחולה עקיפה

10.5 נקודת מבט תיאורטית

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלה על תחולת זכויות אדם במשפט הפרטי, ציינו את "התחולה העקיפה" דרך תקנת הציבור ותום הלב והזכירו את קסטנבאום. ציינו גם ש"תחולה ישירה" על חברות פרטיות אינה הכלל.

10.6 שלד לפתרון שאלה במשפט פרטי

10.7 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
"כל חוזה עם המדינה הוא משפט ציבורי"	החוזה פרטי; יתכנו נורמות ציבוריות חל גם בקיום ובשימוש בזכות, ובכל המשפט
"תום לב חל רק במשא ומתן"	יחסי ממון בחקיקה אזרחית
"הדין הדתי מחליף את כל חלוקת הרכוש"	יש עילה של תום לב במשא ומתן (ס' 12)
"אין עילה אם לא נכרת חוזה"	

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** משפט פרטי: יחסים אופקיים בין שווים; אוטונומיה של הרצון. מקורות חיוב: חוזה, נזיקין, עשיית עושר; זכות חוזית מול קניינית. תום לב (ס' 12, 39, 61(ב)) כעיקרון על, אובייקטיבי; גנז, רוקר, אדרס.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום	ברוב דעות נקבע שהתנאי אינו יכול לעמוד. הנשיא שמגר ראה בו תנאי מקפח בחוזה אחיד והדגיש את האופי המעין־ציבורי של חברה קדישא. השופט ברק ביסס את ההכרעה על תקנת הציבור (ס' 30): פגיעה בלתי מוצדקת בכבוד האדם הופכת תנאי חוזי לבטל. מכאן הלכת התחולה העקיפה. למבחן: זכרו את שני הנימוקים (חוזה אחיד ותקנת ציבור).
ע"א 6024/97 שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשון לציון	העליון קיבל את הערעור: אין די בכך שבחוק קיימת אפשרות חלופית תיאורטית. כשהחלופה אינה זמינה בפועל, הלכת קסטנבאום עומדת בעינה וחברה קדישא אינה יכולה לכפות את התנאי. למבחן: הדגמה של יישום וחיזוק הלכה קודמת.

ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ בהרכב מורחב נקבע שעקרון תום הלב, שמקורו בס' 39 ו־61(ב) לחוק החוזים, הוא עקרון "מלכותי" החל בכל תחומי המשפט, גם בדיני הקניין. מחדלו הממושך של הקונה הראשון, שהכשיל קונה תם לב, שלל ממנו את העדיפות ואת סעד האכיפה; נותרה לו תביעת פיצויים נגד המוכר. למבחן: תום הלב מחוץ לדיני החוזים.

רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון בית המשפט החיל את עקרון תום הלב על היחסים בין בעלי מניות, כביטוי לתחולתו הכללית מעבר לדיני החוזים. הנשיא ברק תיאר את רף ההתנהגות הנדרש: לא זאב ולא מלאך, "אדם לאדם – אדם". מותר לדאוג לאינטרס העצמי, אך בהגינות ובהתחשבות בציפיות הלגיטימיות של הצד השני. למבחן: זכרו את הביטוי.

ד"נ 20/82 אדרס חומרי בנין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג.מ.ב.ה. בדיון הנוסף נקבע ברוב דעות כי דיני עשיית עושר ולא במשפט חלים גם כשבין הצדדים קיימת מערכת יחסים חוזית, וכי בנסיבות מסוימות הנפגע זכאי לרווחי המפר. פסק הדין ממחיש שענפי המשפט הפרטי אינם תאים סגורים. למבחן: הקשר בין חוזים לעשיית עושר.

פרק 11

מבוא למשפט הציבורי

מבוא למשפט הציבורי

✦ **הגדרה — משפט ציבורי** יחסים אנכיים: פרט–שלטון ויחסים בין רשויות. אי־שוויון מובנה.

ענף	עניין
חוקתי	מבנה השלטון וזכויות
מינהלי	פעולת הרשות וביקורת
פלילי	המדינה מול הפרט; חוקיות (ס׳ 1)
מסים	רק בחוק או על פיו (משק המדינה, ס׳ 1)

✔ **שורה תחתונה — חוקיות המינהל** הרשות פועלת רק בגדר הסמכה בחוק (בז׳רנו).

עילה	משמעות
סמכות	חריגה מהסמכה
שיקולים	זרים או חסרים
סבירות	חריגה ממתחם הסבירות (דפי זהב)
מידתיות	פגיעה מעבר לנדרש
צדק טבעי	טיעון ויעדר משוא פנים
הנמקה	סירוב בנימוק

§ **סעיף — צדק טבעי** audi alteram partem; nemo iudex in causa sua.

✦ **הגדרה — נורמות כפולות** המדינה בחוזה כפופה גם לדיני חוזים וגם לשוויון והגינות; מכרזים.

✦ **הגדרה — גוף דו־מהותי** פרטי פורמלית, ממלא תפקיד ציבורי: חלות נורמות ציבוריות.

פסק דין	הלכה

בז׳רנו	הרשות זקוקה להסמכה
דפי זהב	סבירות כעילה עצמאית
דרעי–פנחסי	אי־העברת שר: סבירות קיצונית
5658/23	הסבירות ממשיכה לחול על השרים

מילות מפתח: חוקיות, מתחם הסבירות, שיקול זר, צדק טבעי, ניגוד עניינים, נורמות כפולות.

11.1 מבוא: משפט שבו צד אחד הוא השלטון

11.2 הענפים המרכזיים

ענף	עניינו
משפט חוקתי	מבנה השלטון, חוקי יסוד וזכויות אדם
משפט מינהלי	פעולת הרשויות והביקורת עליהן
משפט פלילי	המדינה מול הפרט בעבירות; עקרון החוקיות (ס׳ 1 לחוק העונשין)
דיני מסים	סמכות המדינה להטיל מסים; ס׳ 1 לחוק־יסוד: משק המדינה: מסים לא יוטלו אלא בחוק או על פיו

! שים לב — אין גבול חד המדינה היא צד גם במשפט פרטי (חוזה רכש), ופרטים עשויים להיות כפופים לדין ציבורי (גוף דו־מהותי). הקריטריון הוא אופי היחסים והכוח השלטוני.

11.3 עקרון החוקיות ועילות הביקורת

✦ **הגדרה — חוקיות המינהל** רשות רשאית לפעול **רק במסגרת הסמכות שהחוק העניק לה**. הפרט חופשי כל עוד אין חוק שמגביל אותו; הרשות מוגבלת ל״ארבע אמותיה״.

עילה	משמעות
חוסר סמכות	פעולה מחוץ להסמכה
שיקולים זרים / אי־שקילת שיקולים רלוונטיים	החלטה על רקע לא ענייני
חוסר סבירות	החלטה החורגת מהותית ממתחם הסבירות
חוסר מידתיות	פגיעה מעבר לנדרש
הפרת כללי הצדק הטבעי	זכות הטיעון והיעדר משוא פנים
אי־הנמקה	סירוב בלי נימוק

11.4 צדק טבעי, הנמקה וניגוד עניינים

11.5 הנורמות הכפולות וגוף דו־מהותי

11.6 נקודת מבט תיאורטית: למה לרסן את השלטון

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** במשפט מינהלי הסדר חשוב: **סמכות**, ואחריה **הליך** (טיעון, משוא פנים, הנמקה), ורק אחר כך **סבירות ומידתיות**. מי שקופץ לסבירות מפספס פגמים ברורים יותר.

11.7 שלד לפתרון שאלה מינהלית

11.8 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״הרשות רשאית כל מה שלא נאסר״	זה כלל הפרט; הרשות זקוקה להסמכה
״תוצאה נכונה מרפאת פגם הליכי״	הפרת זכות הטיעון פוסלת
״בית המשפט יחליף את שיקול הדעת״	מתערב רק בחריגה מהותית ממתחם הסבירות
״המשפט הפלילי הוא פרטי כי יש קורבן״	ההליך בין המדינה לנאשם

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** משפט ציבורי: יחסים אנכיים עם כוח שלטוני; ענפים: חוקתי, מינהלי, פלילי, מסים. חוקיות המינהל: רשות פועלת רק מכוח הסמכה (בז׳רנו).

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג״ץ 1/49 בז׳רנו נ׳ שר המשטרה	בג״ץ קיבל את העתירה: אין צורך שהעותרים יצביעו על חוק שמתיר להם לעבוד; הרשות חייבת להצביע על חוק שמסמיך אותה לאסור. בהיעדר הסמכה האיסור בטל. זו גם ההכרה הראשונה בפסיקה בחופש העיסוק. למבחן: אבן יסוד לעקרון חוקיות המינהל.

בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור — השופט ברק קבע את היסודות שהפכו לדין הנוהג: חוסר סבירות הוא עילה עצמאית; היא נמדדת אובייקטיבית (עובד ציבור סביר); החלטה בלתי סבירה היא החלטה שאינה נותנת משקל ראוי לשיקולים הרלוונטיים; ובית המשפט מתערב רק כשההחלטה חורגת באופן מהותי ממתחם הסבירות. למבחן: ציינו את מחלוקת לנדוי–ברק.

בג"ץ 3094/93 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל — בית המשפט קבע שאי־הפעלת הסמכות להעביר את השר מכהונתו בנסיבות אלה עולה כדי חוסר סבירות קיצוני, בשל הפגיעה באמון הציבור במוסדות השלטון. מכאן "הלכת דרעי–פנחסי". למבחן: דוגמה לסבירות כשיקול אמון הציבור.

בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת — בהרכב של 15 שופטים (1.1.2024) נקבע שלבית המשפט סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים חריגים, וברוב של 8 מול 7 בוטל התיקון. כתוצאה מכך עילת הסבירות ממשיכה לחול גם על החלטות דרג השרים. למבחן: הציגו נייטרלית את הרקע ואת הכרעת הרוב.

פרק 12

נטל ההוכחה ורף ההוכחה

נטל ורף ההוכחה

מושג	משמעות
נטל שכנוע	מי מפסיד אם לא שוכנעו
נטל הבאת ראיות	מי צריך להביא ראיות כעת; עובר בין הצדדים
חזקה	מעבירה נטל או משנה סדר ההוכחה

הליך	רף
אזרחי	מאזן הסתברויות
פלילי	מעבר לספק סביר
סייג	ספק סביר שלא הוסר

§ **סעיף — ס׳ 34כב** (א) הוכחה מעבר לספק סביר; (ב) ספק סביר בסייג מספיק. חזקת היעדר סייג (חוק העונשין).

§ **סעיף — ס׳ 41 לפקודת הנזיקין** הדבר מעיד על עצמו: הנטל עובר לנתבע.

✔ **שורה תחתונה — הצדקה** סיכון הטעות אסימטרי: הרשעת חף חמורה יותר; הרף מטיל סיכון על המדינה (בלקסטון, Winship).

! **שים לב — מלכודת** זיכוי פלילי אינו מונע חיוב אזרחי; הנאשם אינו מוכיח חפות.

פסק דין	הלכה
פודמסקי	לנאשם רק נטל הסבר
דמיאניוק	זיכוי מחמת ספק בזהות
וקנין	ספק רציני והגיוני
קצב	גרסה חלופית סבירה ולא רק אפשרית
זיקרי	אין רף שלישי; ראיות כבדות משקל

מילות מפתח: מאזן הסתברויות, ספק סביר, חזקת החפות, נטל טקטי, חזקה, סייג לאחריות.

12.1 מבוא: שתי שאלות בסיסיות בכל הליך

12.2 נטל ההוכחה

✦ **הגדרה — שני סוגי נטל נטל השכנוע** קובע מי מפסיד אם בית המשפט לא שוכנע בסוף ההליך. הוא קבוע על הצד שמבקש את הסעד: "המוציא מחברו עליו הראיה".

12.3 רף ההוכחה

הליך	רף	הסבר
אזרחי	מאזן ההסתברויות	הגרסה מסתברת יותר מהגרסה שכנגד (מעל 50%)
פלילי	מעבר לספק סביר	רף גבוה, נגזר מחזקת החפות
פלילי: סייג לאחריות	ספק סביר שלא הוסר	די שהנאשם יעורר ספק סביר שמא קיים סייג

§ **סעיף — חוק העונשין** ס׳ 34כב(א): לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם הוכחה מעבר לספק סביר. חזקה סטטוטורית (בחוק העונשין) שלא התקיים סייג לאחריות, ולכן על הנאשם להעלות אותו; אך לפי ס׳ 34כב(ב) די בספק סביר שלא הוסר כדי שהסייג יחול.

! **שים לב — הבחנה בין הליכים** זיכוי בפלילים (למשל מחמת הספק) אינו שולל חיוב בנזיקין על אותו אירוע, כי הרף האזרחי נמוך יותר. בשלב גזר הדין רף ההוכחה לנסיבה מחמירה גבוה מזה של נסיבה מקילה.

12.4 הצדקת הפער: מדוע הרף בפלילים גבוה

12.5 פסיקה מרכזית

12.6 נקודת מבט תיאורטית

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** תמיד ציינו לשני הליכים: נטל (מי) ורף (כמה). ובפלילים ציינו גם את **חזקת החפות** ואת **ס׳ 34כב**. אל תכתבו ש״הנאשם צריך להוכיח חפות״:

12.7 שלד לפתרון שאלה

12.8 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״בפלילים הנאשם מוכיח חפות״	התביעה נושאת בנטל עד הסוף
״רף ביניים קיים בישראל״	הלכה: אין רף שלישי, אך משקל הראיות משתנה
״זיכוי בפלילים מונע חיוב בנזיקין״	הרף האזרחי נמוך
״כל ספק מזכה״	רק ספק סביר, רציני ובעל אחיזה במציאות

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** נטל שכנוע מול נטל הבאת ראיות; המוציא מחברו עליו הראיה; חזקות מעבירות נטל. אזרחי: מאזן הסתברויות; פלילי: מעבר לספק סביר; סייג:

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע״פ 20/51 פודמסקי נ׳ היועץ המשפטי לממשלה	נקבע שכשהתביעה הביאה ראיות לכאורה, עובר לנאשם רק הנטל לתת הסבר; בשום שלב אין עליו להוכיח את חפותו. אם נתן הסבר המתקבל על הדעת ובית המשפט אינו יכול להכריע אם הוא נכון, יש לזכותו מחמת הספק. חובת ההוכחה רובצת על התביעה עד סוף כל הסופות. למבחן: לנאשם נטל טקטי בלבד.
ע״פ 347/88 דמיאניוק נ׳ מדינת ישראל	בית המשפט העליון זיכה אותו, משום שראיות חדשות שהתגלו עוררו ספק סביר בשאלת זהותו כאותו אדם. פסק הדין כולל דיון מפורט בקושי להגדיר ספק סביר ומשמש דוגמה מובהקת לכך שחומרת העבירה אינה מורידה את הרף. למבחן: דוגמה לזיכוי מחמת הספק בתיק קשה.
ע״פ 6295/05 וקנין נ׳ מדינת ישראל	ספק סביר צריך להיות רציני, הגיוני ובעל אחיזה במציאות; לא כל אפשרות רחוקה מצדיקה זיכוי. תמיהות הנוגעות לגרעין האירוע ולמעורבות הנאשם עשויות ליצור ספק סביר, ואילו פרטים שוליים שלא הובהרו אינם מונעים בהכרח הרשעה. למבחן: זכרו את ההבחנה בין גרעין לשוליים.
ע״פ 3372/11 קצב נ׳ מדינת ישראל	הערעור נדחה. נקבע שגרסה חלופית יוצרת ספק סביר רק אם היא סבירה ולא רק אפשרית, ושיש לבחון אם הראיות מעוררות ספק בגרעין האירוע. בית המשפט הדגיש שהמערער אינו מורשע משום שהוא שקרן, אלא משום שעדות המתלוננת נמצאה מהימנה וחומר הראיות לא העלה ספק סביר. למבחן: מבחן הסבירות של גרסה חלופית.

ע"א 475/81 זיקרי נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ

נחלקו הדעות: השופט בך סבר שיש רף ביניים לטענות המטילות על הצד השני סטיגמה של עבירה חמורה; השופט ברק סבר שאין ליצור רף שלישי, אלא שהרף נשאר מאזן ההסתברויות, וכמות הראיות ומשקלן מותאמים לחומרת הטענה. המסקנה המעשית: טענה כזו דורשת ראיות כבדות משקל. למבחן: שתי הגישות והמסקנה המשותפת.

פרק 13

אתיקה ומקצועות המשפט

אתיקה ומקצועות המשפט

תפקיד	מהות
עורך דין	ייצוג וייעוץ, חובה כפולה
שופט	הכרעה ניטרלית
תובע	האינטרס הציבורי
נוטריון	אימות מסמכים
בורר/מגשר	יישוב סכסוכים

✔ **שורה תחתונה — חובה כפולה** ללקוח (נאמנות) ולבית המשפט (עשיית משפט).

✦ **הגדרה — סודיות מול חיסיון** סודיות: חובה אתית רחבה. חיסיון: כלל ראייתי נגד גילוי בהליך.

§ **סעיף — ניגוד עניינים** אין לייצג אינטרסים מנוגדים.

! **שים לב — הודאת לקוח** מותר לכפור ולדרוש הוכחה; אסור להציג ראיה שקרית.

§ **סעיף — פסלות שופט (ס׳ 77א)** חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

✔ **שורה תחתונה — משמעת** אזהרה, נזיפה, קנס, השעיה, הוצאה; לא מאסר. כולל מעשה שאינו הולם.

פסק דין	הלכה
לוי נ׳ שרמן	האתיקה מעצבת את סטנדרט הזהירות
גיאות	להזהיר ולהסביר כשהלקוח מתעקש
היינוביץ	חובת זהירות גם לצד שלישי
שפטל	נוסחת הגרעין הקשה

מילות מפתח: קצין בית המשפט, סודיות, חיסיון, ניגוד עניינים, פסלות, גרעין קשה, מוסר תפקיד.

13.1 מבוא: מי הם אנשי המשפט ומהם כללי ההתנהגות שלהם

13.2 מקצועות המשפט

תפקיד	מהות
עורך דין	ייצוג וייעוץ; כפוף לחוק לשכת עורכי הדין ולכללי האתיקה
שופט	הכרעה ניטרלית ועצמאית
תובע	ייצוג האינטרס הציבורי בהליך הפלילי
נוטריון	אימות מסמכים ופעולות ייעודיות לפי חוק
בורר ומגשר	יישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט

13.3 אתיקה מקצועית של עורך דין

✦ **הגדרה — חובות העל** חובה כפולה: נאמנות ומסירות ללקוח, וסיוע לבית המשפט לעשות משפט. עורך הדין הוא "קצין בית המשפט", ולכן אינו רק "שכיר חרב" של הלקוח.

! שים לב — הודאת לקוח בפלילים נאשם שהודה בפני סנגורו וביקש לכפור באשמה: הסנגור רשאי לכפור בעובדות ולדרוש מהתביעה להוכיח, אך אסור לו להציג ראיה או עדות שהוא יודע שהן שקריות.

13.4 משמעת ואתיקה שיפוטית

13.5 נקודת מבט תיאורטית: מוסר התפקיד

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בשאלות אתיקה נתחו לפי שלוש חובות: **ללקוח**, **לבית המשפט**, **לציבור ולעמיתים**. כשהחובות מתנגשות, כלל האתיקה מחייב איזון. אל תכתבו מספרי כללים אם אינכם בטוחים; כתבו "לפי כללי האתיקה".

13.6 שלד לפתרון שאלה

13.7 מלכודות נפוצות

הטענה	מדוע שגויה
״עורך הדין חייב לציית לכל הוראת לקוח״	חייב גם לבית המשפט ולכללי האתיקה
״סודיות וחיסיון הם אותו דבר״	סודיות אתית רחבה; חיסיון כלל ראייתי
״מותר להציג עד שקרן אם הלקוח ביקש״	אסור להציג ראיה שהוא יודע שהיא שקרית
״בית דין משמעתי יכול לשלוח למאסר״	אינו מוסמך להטיל מאסר
״כל אדם יכול לנסח הסכם בתמורה״	פעולה מיוחדת לעורכי דין

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** מקצועות: עורך דין, שופט, תובע, נוטריון, בורר ומגשר. חובה כפולה של עורך הדין: ללקוח ולבית המשפט; סודיות, חיסיון, ניגוד עניינים, הגינות.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
ע״א 37/86 לוי נ׳ שרמן	נקבע שחוק לשכת עורכי הדין והכללים שהותקנו מכוחו, אף שעניינם אתיקה מקצועית, משמשים מקור לקביעת סטנדרט המיומנות והזהירות שעורך דין חב ללקוחו. כך הנורמה האתית ״מתורגמת״ לחובת זהירות בנזיקין. למבחן: הקשר בין אתיקה לנזיקין.
ע״א 7633/12 קבוצת גיאות בע״מ נ׳ גולדפרב לוי ערן מאירי צפריר ושות׳	הערעור נדחה. כשרצון הלקוח מנוגד לייעוץ, על עורך הדין להזהיר את הלקוח ולהסביר את הסיכויים והסיכונים. עוצמת החובה תלויה בזהות הלקוח ומעורבותו, בגודל הסיכון ובמורכבות הסוגיה; התפטרות שמורה למקרי קיצון. למבחן: פירוט פרמטרים לחובת האזהרה.
ע״א 2725/91 היינוביץ נ׳ גלעדי	הוכר שבנסיבות מסוימות קיימת חובת זהירות של עורך דין גם כלפי צד שלישי שאינו לקוחו. הפסיקה לא קבעה גבולות חדים לחובה, והיקפה נבחן ממקרה למקרה. למבחן: הרחבת החובה מעבר ליחסי לקוח.
על״ע 1734/00 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ׳ שפטל	נקבעה נוסחת איזון: ככל שהדברים קרובים ל״גרעין הקשה״ של המקצוע (כמו הופעה בבית המשפט) נדרש איפוק רב; ככל שהם רחוקים ממנו, משקלו של חופש הביטוי עולה. בנסיבות העניין ניתן משקל רב לחופש הביטוי ונקבע שאין עבירה אתית. למבחן: נוסחת הגרעין הקשה.

פרק 14

כתיבה וטיעון משפטי

כתיבה וטיעון משפטי

✦ **הגדרה — סילוגיזם** הנחה עליונה (כלל) + הנחה תחתונה (עובדות) = מסקנה.

אות	שלב
I	Issue: השאלה
R	Rule: הכלל
A	Application: יישום עם ״שכן״
C	Conclusion: מסקנה

! **שים לב — הציון נמצא ביישום** כלל + עובדות בלי חיבור אינם יישום.

מסמך	אופי
תזכיר	אובייקטיבי
כתב טענות	משכנע, לא כוזב
חוות דעת	מאוזנת
סיכומים	בעל פה או בכתב

§ **סעיף — כללי האזכור** ע״א 37/86 לוי נ׳ שרמן, פ״ד מד(4) 446, 461 (1990); בלי ״ואח׳״.

✔ **שורה תחתונה — לשון** לשון פרקליטים סבירה; התווית המעליבה אסורה (10/81, 9/89).

! **שים לב — בינה מלאכותית** אסור להגיש אסמכתה שלא נבדקה; סנקציות עתידיות: דחייה, הוצאות אישיות, דין משמעתי.

הוגה	רעיון
פרלמן	טיעון משכנע בפני קהל

טולמין	טענה, נימוקים, הצדקה
לוולין	כללי פרשנות סותרים

מילות מפתח: IRAC, יישום, שכן, לשון פרקליטים, אזכור אחיד, אסמכתה בדויה.

14.1 מבוא: מדוע כתיבה וטיעון הם מיומנות יסוד

14.2 מאפייני הכתיבה המשפטית

14.3 מבנה הטיעון: סילוגיזם ו־IRAC

✦ **הגדרה — סילוגיזם משפטי** הנחה עליונה (הכלל המשפטי) + הנחה תחתונה (העובדות שתורגמו לרכיבי הכלל) = מסקנה. זהו הבסיס לכל טיעון שיפוטי.

אות	שלב	תוכן
I	Issue	השאלה המשפטית
R	Rule	הכלל והמקור שלו
A	Application	החלת כל רכיב בכלל על העובדות והסבר "שכן"
C	Conclusion	המסקנה

! שים לב — הלב של השאלה: יישום הצגת הכלל ואחריה סיפור מחדש של העובדות ללא חיבור ביניהם אינה יישום. יש להצמיד עובדה לרכיב ולהסביר מדוע הוא מתקיים או לא.

14.4 סוגי מסמכים

מסמך	מטרה	אופי
תזכיר משפטי פנימי	ייעוץ פנימי	אובייקטיבי; מציג גם את החולשות
כתב טענות	הצגת עמדה לבית המשפט	משכנע לטובת הלקוח, אך אינו כוזב
חוות דעת	תשובה לשאלה משפטית	מאוזנת ומנומקת
סיכומים	סיכום ההליך ובקשת הכרעה	מבוסס על הראיות, בעל פה או בכתב
חוזה	יצירת מסגרת לחיובים	ברור ושלם

14.5 אזכורים וסגנון

14.6 לשון ועלבונות: הפסיקה המשמעתית

14.7 בינה מלאכותית ואסמכתאות

14.8 נקודת מבט תיאורטית: טיעון ורטוריקה

★ **טיפ למבחן — טיפ למבחן** בחינה נבדקת לפי יישום. כתבו: כלל, ואז **"שכן"**, ואז עובדה מהשאלה. התייחסו לטענת הצד שכנגד, והסיקו מסקנה מנומקת. אל תצטטו פסק דין שאינכם בטוחים בו:

14.9 שלד לפתרון שאלה

14.10 מלכודות נפוצות

הטעות	התיקון
הצגת הכלל ללא יישום	החלת כל רכיב על העובדות
מסקנה בלי נימוק	הסבר "שכן"
לשון מעליבה	לשון פרקליטים סבירה
ציטוט שלא נבדק	לוודא קיום ואימות במקור
התעלמות מהצד שכנגד	התמודדות עם טיעוניו

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** סילוגיזם: כלל, עובדות, מסקנה; IRAC והדגש על היישום. סוגי מסמכים: תזכיר (אובייקטיבי), כתב טענות (משכנע אך לא כוזב), חוות דעת, סיכומים.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה

בג"ץ 38379-12-24 פלונית נ' בית הדין השרעי (2025)	העתירה נדחתה לגופה. בית המשפט קבע שהגשת אסמכתאות בדויות פוגעת בלקוח, בבית המשפט, בצד שכנגד ובמקצוע, ופירט סנקציות לעתיד: דחייה על הסף, הוצאות אישיות על עורך הדין והפניה לדין משמעתי. כמקרה ראשון לא הוטלו סנקציות, אך הובהר שבעתיד יש להפעיל את הכלים. למבחן: חובת הוידוא של אסמכתאות.
על"ע 10/81 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' פלוני	נקבע שהלשון צריכה להיות לשון פרקליטים סבירה ולא לשון השוק, כי מעורך דין נדרשים אחריות ושיקול לשון רבים יותר. ביטוי רלוונטי לטענה לגופה נבחן בסבירות; ביטוי שכל תכליתו להגדיל רושם ייבחן בקפדנות יתרה. למבחן: סטנדרט הלשון.
על"ע 7/70 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' סלומון	מותר לעורך דין לטעון טענות עובדתיות אפילו כאלה הפוגעות בכבודו של שופט, אך אסור לו לצאת מגדרי הנימוס. עליו להימנע מלהשליך לחלל בית המשפט דברים שאינם רלוונטיים או שאינו רשאי להוכיח באותה ערכאה, ולנסח את דבריו בסגנון ההולם את המקצוע. למבחן: איזון בין חופש הטיעון לנימוס.
על"ע 9/89 יובל נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין	ההרשעה אושרה. גם בהנחה שהיה יסוד לטענה, די היה לכתוב שהדברים אינם אמת; התוספת "במצח נחושה" לא נועדה אלא להעליב ולפגוע. הלקח לכתיבה: לטעון את העובדה, לא להוסיף לה תוויות. למבחן: ההבחנה בין טענה לגיטימית לבין עלבון.

פרק 15

מבוא לפתרון בעיה משפטית

מבוא לפתרון בעיה משפטית

✔ **שורה תחתונה — סדר הפתרון** הוראה, סוגיות, תכנון; סף, גוף, סעד.

שלב	תוכן
Issue	השאלה המשפטית
Rule	הכלל והמקור
Application	עובדה + שכן + הכרעה, שני הצדדים
Conclusion	מסקנה והמלצה

★ **טיפ למבחן — יישום** הציון ביישום; לכל רכיב בכלל: עובדה, "שכן", הכרעה.

✦ **הגדרה — טענה חלופית** "וגם אם…" כדי לנתח את הסוגיות הבאות ולהציג עילות חלופיות.

✦ **הגדרה — ניתוח מותנה** עובדה חסרה: אם X אז A; אם Y אז B.

! **שים לב — שפיכת חומר** ידע שאינו מיושם על העובדות אינו מזכה בנקודות.

! **שים לב — מילים מוחלטות** "תמיד" ו"בכל מקרה": לבדוק חריגים (למשל ס' 3(ב) לחוק החוזים).

פסק דין	לקח
רסלר	סף: עמידה ושפיטות
רונאל	מיצוי הליכים כעילת סף
חטיב	אמת מידה להתערבות בג"ץ בבתי הדין לעבודה
בית ששון	השתק שיפוטי

מילות מפתח: סוגיה, IRAC, יישום, סף, טענה חלופית, ניתוח מותנה, סעד.

15.1 מבוא: המיומנות המעשית המרכזית

15.2 קריאת השאלה

✦ **הגדרה — סוגיה** שאלה משפטית שהעובדות מעוררות ושאפשר לטעון לגביה לשני הכיוונים. לא כל עובדה היא סוגיה, ולא כל נושא שנלמד הוא סוגיה בשאלה.

15.3 שיטת IRAC והדגש על היישום

שלב	תוכן	טעות נפוצה
Issue	זיהוי השאלה המשפטית	ניסוח כללי מדי
Rule	הכלל והמקור (חוק, פסיקה)	רשימת סעיפים בלי קשר לעובדות
Application	החלת כל רכיב על העובדות, כולל טענות שני הצדדים והכרעה שפיכת חומר, סיפור מחדש של עובדות	
Conclusion	מסקנה ברורה, בצירוף המלצה אם נדרש	מסקנה ״קופצת״

★ **טיפ למבחן — נקודת מפתח** הציון נמצא ביישום. לכל רכיב בכלל: **עובדה + ״שכן״ + הכרעה**. הציגו את טענות שני הצדדים כדי להראות שזיהיתם את המחלוקת, וחזקו את המסקנה.

15.4 סדר הדיון: סף, גוף, סעד

15.5 טענות חלופיות וניתוח מותנה

15.6 נקודת מבט תיאורטית: מהו חשיבה משפטית

15.7 דוגמה פתורה

15.8 ניהול זמן

15.9 מלכודות נפוצות

הטעות	התיקון
מסקנה שלילית ועצירה	להוסיף ״וגם אם״ ולנתח הלאה
שפיכת חומר	לצמצם את הכלל ולהרחיב ביישום
התעלמות מהסף	לבדוק קודם עמידה, סמכות, מיצוי
הצגת צד אחד	לשקול את טענות הצד שכנגד
השמטת הסעד	לסיים בסעד המתאים

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** קוראים קודם את ההוראה; מזהים סוגיות; מתכננים. IRAC והציון ביישום: עובדה + ״שכן״ + הכרעה. סדר: סף, גוף, סעד. טענה חלופית וניתוח מותנה.

שרשרת פסיקה בפרק

פסק דין	ההלכה
בג״ץ 910/86 רסלר נ׳ שר הביטחון	העתירה נדחתה לגופה, אך נקבעו הלכות יסוד בשאלות סף: ברק הכיר בעותר הציבורי בבעיה ציבורית הנוגעת לשלטון החוק, והבחין בין שפיטות נורמטיבית לשפיטות מוסדית, וקבע שהעתירה שפיטה בשני המובנים. למבחן: דוגמה לכך שבודקים עמידה ושפיטות לפני גוף העניין.
בג״ץ 2624/97 רונאל נ׳ ממשלת ישראל	נפסק שגם כשהרשות עלולה להתעכב בתשובתה, על הפונה לתת לה שהות סבירה, לפי הנסיבות, לבחון את פנייתו. מיצוי הליכים הוא עילת סף: עתירה שלא עמדה בה עלולה להידחות בלי דיון לגופה. לקח שיטתי: בודקים את הסף לפני הגוף.
בג״ץ 525/84 חטיב נ׳ בית הדין הארצי לעבודה	נקבע שבג״ץ אינו יושב כערכאת ערעור על בתי הדין לעבודה, ומתערב רק כשנפלה טעות משפטית מהותית ושיקולי צדק מחייבים התערבות. ההלכה מצוטטת עד היום. לקח שיטתי: לפני שמנתחים את גוף הסוגיה מזהים איזו אמת מידה חלה על הגוף המכריע.
רע״א 4224/04 בית ששון בע״מ נ׳ שיכון עובדים והשקעות בע״מ	נקבעו תנאי ההשתק השיפוטי: בעל דין שטען טענה בהליך קודם, והטענה התקבלה באותו הליך, מנוע מלטעון טענה הפוכה בהליך מאוחר, גם אם אינו מראה שזכה בסופו של המשפט. לקח שיטתי: חלופות מותרות, אך לא קפיצה בין עמדות סותרות כדי להרוויח פעמיים.